

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 409: estese a lo que se resuelve a continuación.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que a folio 409 la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (“Conadecus”) interpuso recurso de reclamación contra la decisión de 3 de septiembre de 2026 dictada en estos autos, que determinó ejercer la facultad conferida por el artículo 18 N° 4 del Decreto Ley N° 211 (“D.L. N° 211”) en relación con una de las cuatro medidas específicas que fueron objeto del proceso, relativa a la creación de un registro de beneficiarios finales;

Segundo: Que el artículo 18 N° 4 del D.L. N° 211 dispone: “[e]l Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes (...) 4) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en condiciones no competitivas. En todo caso, el ministro receptor de la propuesta deberá manifestar su parecer sobre ésta. La respuesta será publicada en el sitio electrónico institucional del Tribunal, de la Fiscalía y del Ministerio de que se trate”;

Tercero: Que la atribución otorgada a este Tribunal para proponer la modificación o derogación de ciertos preceptos legales y reglamentarios fue otorgada a la Comisión Resolutiva por el inciso final del artículo 5° del texto original del D.L. N° 211. Esa disposición señalaba que “[l]a Comisión Resolutiva podrá solicitar la modificación o derogación de preceptos legales o reglamentarios (...) en cuanto limitando o eliminando la libre competencia, los estime perjudiciales para el interés común”. A pesar de las sucesivas modificaciones a las normas de defensa de la competencia, que incluyeron la creación de este Tribunal en reemplazo de las Comisiones, esta atribución del órgano especializado en libre competencia se ha mantenido en lo sustancial;

Cuarto: Que, tanto por su origen histórico como por su sentido y alcance, se desprende que el ejercicio de la atribución conferida en el numeral 4 del artículo 18 del D.L. N° 211 no tiene naturaleza jurisdiccional. En efecto, la doctrina entiende la jurisdicción como la satisfacción de un interés jurídico mediante la aplicación en el

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

proceso de la ley, conociendo, resolviendo y, eventualmente, haciendo ejecutar lo juzgado (Bordalí, Andrés, *Derecho Jurisdiccional*, Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 53-54). Así, la función jurisdiccional supone una decisión con carácter vinculante respecto de uno o más individuos;

Quinto: Que, en este sentido, la atribución del numeral 4 del artículo 18, es fundamentalmente diferente a las establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 5 del mismo artículo, cuyo ejercicio necesariamente da lugar a decisiones vinculantes, ya sea para quienes han sido parte o intervenido en el proceso (como ocurre respecto de las atribuciones referidas en los numerales 1, 2 y 5), ya sea para la generalidad de los agentes que participan de un mercado (como ocurre en el caso de la atribución del numeral 3). En efecto, el resultado del procedimiento de recomendación normativa (numeral 4) es una mera proposición al Poder Ejecutivo, que puede acogerla o rechazarla, donde la única carga recae sobre el Ministro de Estado receptor de la misma, y que está limitada a la obligación de “manifestar su parecer”. En otras palabras, al decidir ejercer o no esta atribución, este Tribunal no decide un conflicto entre partes, ni determina la comisión de infracciones —como ocurre en el marco del procedimiento contencioso y en la resolución del recurso especial de revisión contra las decisiones del Fiscal Nacional Económico que hayan prohibido operaciones de concentración—, ni otorga derechos ni establece obligaciones —como ocurre en la llamada potestad consultiva y en la de dictación de instrucciones de carácter general—;

Sexto: Que no obsta a esta interpretación el hecho que, tras la dictación de la ley N° 20.945 en 2016, la proposición de recomendación normativa deba sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 31 del D.L. N° 211. Ante todo, la referida reforma sólo vino a consagrar la práctica anterior de este Tribunal, la que a su vez tuvo origen en lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 18 de mayo de 2010. Allí, conociendo de un recurso de reclamación contra la Sentencia 85/2009 de este Tribunal, la Excma. Corte afirmó que el ejercicio de esta atribución “(...) no [puede] formar parte de una sentencia llamada a dirimir un conflicto contencioso (...)”, lo que llevó al Tribunal a adoptar el procedimiento no contencioso en la materia;

Séptimo: Que el hecho de que la atribución pueda ejercerse sólo después de llevar a cabo un procedimiento no contencioso, donde no hay contienda entre partes, sino únicamente antecedentes aportados por terceros interesados, sólo da cuenta de la necesidad de que la decisión que se adopte esté adecuadamente fundada y

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

que exista una oportunidad para manifestarse sobre la conveniencia o no de eventuales propuestas de reforma legal o reglamentaria desde la perspectiva de la libre competencia, en un símil a las consultas públicas en sede administrativa, incorporadas en nuestra legislación por la Ley N° 20.500;

Octavo: Que, adicionalmente, se ha entendido que el ejercicio de la atribución del numeral 4 del artículo 18, es discrecional para este Tribunal, a quien se le ha conferido dado su carácter técnico y especializado en libre competencia y puede ser ejercida de oficio o a solicitud de parte;

Noveno: Que confirma la interpretación anterior el que la mencionada Ley N° 20.945 haya conferido a la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) en el actual artículo 39 q) del D.L. N° 211, una facultad descrita en términos prácticamente idénticos a los del artículo 18 N° 4. Incluso, el mensaje de la Ley 20.945 proponía derechamente “trasladar” esta facultad a la FNE (Historia de la Ley N° 20.945, p. 13) y sólo durante la tramitación del proyecto se optó por mantener la atribución, además, en este Tribunal;

Décimo: Que esta potestad también es ejercida por la FNE de manera discrecional, sin que se prevean recursos ante un órgano jurisdiccional cuando es ese organismo quien decide ejercerla ni tampoco cuando no la ejerce. Así, por la naturaleza de la atribución de que se trata, queda excluida del control de juridicidad propio de las actuaciones del poder estatal que suponen el ejercicio de una potestad pública, lo que permite inferir, a su vez, que su ejercicio por este Tribunal no supone una actividad jurisdiccional;

Undécimo: Que, finalmente, el inciso final del artículo 31 del D.L. N° 211, establece que “[l]as resoluciones de término, sea que fijen o no condiciones, solo podrán ser objeto del recurso de reclamación (...)”. Esta norma fue objeto de reforma por la Ley N° 20.361, de 2009, en tanto el texto antes vigente disponía “Las resoluciones que fijen condiciones que deben ser cumplidas en actos o contratos podrán también ser objeto de recurso de reclamación”. De acuerdo con la historia fidedigna de su establecimiento, la justificación de esa reforma fue, en palabras del Fiscal Nacional Económico de la época, el hecho que “[estaba] muy limitado el derecho a recurrir, sólo es procedente respecto de resoluciones que fijen condiciones, mas no la resolución que aprueba o deniega pura y simplemente” (Historia de la Ley N° 20.361, p. 222). Así, es claro que el sentido de la modificación legal fue extender la aplicación del recurso de reclamación en el marco del ejercicio de la atribución

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

prevista en el art. 18 N° 2 del D.L. N° 211, única hipótesis en la que efectivamente se pueden fijar condiciones; y

Duodécimo: Que la improcedencia del recurso de reclamación en contra de la decisión del Tribunal respecto de ejercer o no (y en qué términos) la facultad prevista en el artículo 18 N° 4 del D.L. N° 211 ha sido refrendada por la Excma. Corte Suprema, que ha resuelto que dicha facultad *“no tiene naturaleza jurisdiccional, toda vez que más allá de la inexistencia de un conflicto entre partes, lo relevante es que en el caso concreto el ejercicio de tal potestad, por una parte, es facultativa para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, por otro lado, una vez que se ejerce, no se genera un acto jurisdiccional de carácter vinculante, toda vez que la decisión se agota al poner en conocimiento del Poder Ejecutivo la recomendación, sin que se pueda exigir el cumplimiento de aquello que simplemente se propone, por lo que éste puede acogerla o rechazarla de forma discrecional, destacándose así, tal como lo refiere el TDLC, una diferencia fundamental con las atribuciones establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 5 del referido artículo 18, cuyo ejercicio necesariamente da lugar a decisiones vinculantes para las partes o para los agentes del mercado. En este orden de ideas, debe enfatizarse que la sola circunstancia de que la solicitud con que inician estos autos se tramitara en conformidad con el procedimiento no contencioso, no es suficiente para hacer reclamable la resolución que pone término al procedimiento, toda vez que aquello no altera la esencia de la facultad discrecional consagrada en el artículo 18 N° 4 del Decreto Ley N° 211”* (resolución de 27 de marzo de 2023 en los autos rol N° 114.692-2022, c. 4°);

Décimotercero: Que, en consideración a lo expuesto, cabe concluir que el ejercicio de la atribución conferida a este Tribunal en el numeral 4 del artículo 18 del D.L. N° 211 no es susceptible de recurso de reclamación para ante la Excma. Corte Suprema;

SE RESUELVE: No ha lugar al recurso de reclamación, por improcedente.

A los folios 410 y 411: téngase presente.

Notifíquese por el estado diario.

Rol ERN N° 32-23.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



AE0918A3-0A77-4350-A6A8-DA6DA6AF3C05

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.